

C8a. CC Cba. 21/5/07. AI N° 168. Trib. de origen: Juzg. 9a. CC Cba. "Residuos Patógenos SA y Otros c/ Estado Provincial – Amparo - Recurso de Apelación". Dres. Héctor Hugo Liendo, José Manuel Díaz Reyna y Silvia B. Palacio de Caeiro

■

AUTO NUMERO: 168

Córdoba, veintiuno de Mayo dos mil siete.

Y VISTO: El recurso de apelación interpuesto fundadamente por los actores a fs. 204/209 de estos autos caratulados "RESIDUOS PATOGENOS S.A. Y OTROS C/ ESTADO PROVINCIAL – AMPARO – RECURSO DE APELACION – EXP. N°1280567/36" contra el decreto de fecha 6/5/07 (fs.200/201), que dice: "Córdoba, 6 de mayo de 2007. Téngase a los comparecientes por parte, en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Emplácese a los interesados para que en el término de dos días depositen el pago de la tasa de justicia, bajo apercibimiento del art. 86 del c. de c. Asimismo, emplácese a los amparistas y al Dr. Ortiz Pellegrini para que en el término de 48 hs. cumplimenten con el art. 17 inc. b, ley 6468 y en 72 hs. con el art. 35, ley 5805, bajo apercibimiento de ley. Siendo débito del suscripto efectuar un análisis previo y pormenorizado en orden a la admisibilidad formal de la pretensión incoada -art. 2, ley 4915- y a mérito de reciente doctrina judicial del TSJ, al definir que "...tratándose del ejercicio de una vía extraordinaria como el amparo, concebida para garantizar la protección de derechos fundamentales, el análisis del cabal cumplimiento de los recaudos que hacen a la procedencia formal de este remedio excepcional deviene en una premisa necesaria de la decisión judicial a dictar en orden a la pretensión sustancial esgrimida, toda vez que la existencia o no de dichos presupuestos condiciona la competencia del Tribunal para emitir un decisorio válido sobre el fondo de la materia en debate, la acción de amparo es un proceso constitucional autónomo, caracterizado como una vía procesal "expedita y rápida" condicionada entre otros recaudos a que "...no exista otro medio judicial más idóneo..." (art. 43, CN). Ello aún cuando hoy, frente al texto del nuevo artículo 43 de la Carta Magna, no pueda sostenerse ya como requisito de procedencia la "inexistencia" de una vía idónea para la tutela del derecho que se invoca como conculcado, sin embargo, no cabe admitirlo cuando esa protección es susceptible de ser obtenida a través de otro procedimiento administrativo o jurisdiccional que, frente a las particularidades del caso, se presente como "el más idóneo..." (TSJ, en pleno, Sent. N° 17, del 29/12/03, in re: "CARRER, Mario y otro c/ CAMINOS DE LAS SIERRAS SA- ACCIÓN DE AMPARO -RECURSO DE CASACIÓN). Cabe insistir en el aspecto relacionado con la incidencia que el nuevo texto del art. 43, CN tiene sobre la ley provincial 4915, más precisamente sobre los presupuestos de admisibilidad contemplados en el art. 2. En ese sentido, no coincidiendo con los amparistas nuestro máximo tribunal local, entre otros precedentes, ha destacado que el art. 43, CN "...no obsta la vigencia de las normas reglamentarias anteriores, en tanto éstas

no se opongan a la letra, a su espíritu, o resulten incompatibles con el remedio judicial instituido en el citado precepto constitucional como un instrumento ágil, eficaz y expeditivo para asegurar la vigencia cierta de los derechos constitucionales..." (in re Miranda Liliana y otros c/Municipalidad de Córdoba - Amparo TSJ en pleno Sentencia n° 57 del 18/5/99). A mérito de ello, y siguiendo calificada doctrina deviene menester practicar el juicio de admisibilidad en aras de determinar el rechazo in límine de la acción -art. 3, Ley 4915-, con base, pura y exclusiva en los presupuestos previstos en el art. 2, ley 4915. En orden a ello, respecto de la inexistencia de otro medio judicial más idóneo los amparistas manifiestan en el punto IV.4 al aludir sobre el alcance del art. 17 del pliego de condiciones generales, que las consultas y/o aclaraciones de los posibles oferentes se receptorían hasta 7 días hábiles - anteriores a la fecha de la apertura. Sostienen que teniendo en cuenta el primer día de publicación en el BOP -23/4/07- hasta la conclusión de la misma -27/4/07- sólo restan cuatro días hábiles antes de la presentación de oferta. Tal circunstancia sumada a que la compra de los pliegos por el actor Jarast, lo fue con fecha 2/5/07 y el resto de los actores -4/5/07- no les permite hacer uso de este derecho. Así las cosas, la apreciación aparece ostensiblemente errada porque de modo alguno puede interpretarse que el plazo debe computarse a partir del último día de publicación, ya que de afirmar ello nunca se cumpliría el término de siete días hábiles anteriores a la fecha de apertura. En realidad el equívoco de los amparistas radica en confundir el plazo de publicación que pone en conocimiento el llamado a licitación pública con el plazo para efectuar las consultas y/o aclaraciones referidas a los pliegos. En síntesis, que los amparistas hubiesen adquirido los pliegos en las fechas que indican -2/5/07 y 4/5/07- debió traducirse en un mayor celo y premura para realizar la consulta o solicitud de aclaración. Respecto del actor Jarast -compra del pliego en fecha 2/5/07- no se advierte cual ha sido su imposibilidad para ejercer el derecho que le asistía de efectuar las consultas conforme lo reglamentaba el pliego; mientras que en el caso de los restantes amparistas que adquirieron el pliego el 4/5/07, debieron, de no poder utilizar esta facultad, plantear los recursos administrativos con fundamento en las consultas o solicitudes de aclaración. Es más, nada manifiestan los demandantes respecto de cual ha sido el impedimento que tuvieron para interponer el mismo día cuatro de mayo del cte. año los recursos contemplados en la ley 6658 -procedimiento administrativo provincial, arts. 80 y 83 -reconsideración y jerárquico- con el consecuente pedido de suspensión de los efectos del acto administrativo consistente en el llamado a licitación y en las cláusulas del pliego que estos advierten o tachan de oscuras y susceptibles de aclaración - art. 91, ley 6658-. En síntesis el aspecto temporal de la época de adquisición del pliego de manera alguna puede enervar lo precedentemente concluido, en todo caso, la circunstancia esgrimida por los amparistas como actuales prestadores del objeto de la licitación, les exigía la adopción de recaudos idóneos para esclarecer de manera inmediata las dudas que el pliego les traía aparejado para la formulación de su oferta. No escapa al suscripto que desde el momento de publicación del llamado, -23/4/07- a la fecha de presentación de la

oferta -7/5/07- el tiempo resulta razonablemente exiguo; pero justamente tal aspecto es el que debió exigir de los amparistas su rápida reacción por los carriles administrativos pertinentes. En definitiva, de lo antes expuesto surge configurada la primer causal de inadmisibilidad respecto de la existencia de otros medios administrativos idóneos para procurar el objeto de la acción judicial impetrada - art. 17 pliego de condiciones generales, art. 80, 83 y 91, ley 6658 (art. 2 inc a, ley 4915). No es en vano que se predique "...La existencia de remedios procesales ordinarios y adecuados para la tutela del derecho del recurrente, excluye la procedencia de la acción de amparo, siendo insuficiente a ese fin el perjuicio que pueda ocasionar la dilación de los procedimientos corrientes. Ello es así, porque el amparo es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige para su apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita. La carga de demostrar la inexistencia o insuficiencia de otras vías que permitan obtener la protección que se pretende debe ser suplida por quien demanda. (Del voto del doctor Fayt CSJN in re Prodelco c. Poder Ejecutivo Nacional Fallos: 321:1252). A mayor abundamiento y sobre este tópico deben desarrollarse dos argumentos mas que redundan en la conclusión antes adelantada. El primero se vincula con lo manifestado por los amparistas en el punto "otro si digo" y en particular respecto del actor, Adolfo Jarast en cuanto se manifiesta receptor vía fax de la circular aclaratoria n° 1 dictada en el marco de esta licitación que posterga la fecha de presentación de las ofertas y propuestas hasta el 28/5/07 a las 11:00 hs. Si bien no surge de las condiciones del pliego que este sea el modo hábil de notificación de las decisiones adoptadas por el comitente, tal aspecto no deja de trascender en cuanto el proceder que los accionantes debieron adoptar con base en la circular receptada, que no era otra que incoar los remedios y recursos administrativos antes enunciados. Tal comportamiento era de prever con base en la verosimilitud que de ella se desprende respecto de la prórroga del plazo de presentación y apertura de oferta. La misma puede y autoriza a inferirse de la existencia de un sello y firma estampada al pie de ella indicando cargo y ministerio del que emana, siendo éste coincidente con quien llama a licitación y por el objeto de que se trata. Desde otra óptica, pero sobre la misma causal de admisibilidad, doctrina calificada ha expuesto "...la aptitud o ineptitud de las vías paralelas como manera de juzgar la viabilidad del amparo dependerá del caso concreto y no puede ser determinada en abstracto..." (Keselman, Marcelino "El amparo en la jurisprudencia del TSJ p. 34 Ed. Marcos Lerner, Septiembre 2001). Denuncian los demandantes la pretendida superposición de contratos entre los que son titulares y el futuro adjudicatario; pero no puede coincidirse con ello, porque no solo los amparistas se califican de oferentes sino que además la aleatoriedad del resultado final y del momento en que efectivamente se produzca la adjudicación harán que solo en tal circunstancia pueda afirmarse sobre la superposición de contrato. Claro

está en la medida que alguno de ellos no fuere adjudicatario porque de ser así no existiría agravio. Es mas no puede ser la acción de amparo la vía apta para presagiarse eventuales perdedores en la contratación y ante ello sin haber articulado los remedios administrativos idóneos querer preservar las contrataciones vigentes por eventuales y futuras adjudicaciones a personas distintas de cualquiera de los cuatro amparistas. Por todo lo expuesto y normas invocadas, RESUELVO: Inadmitir el recurso de amparo por configurarse la causal del art. 2 inc. a, ley 4915.". Que el mencionado recurso que fuera concedido a fs. 209. Radicados los autos ante este Tribunal y dictado el decreto de autos y a estudio, el proveído queda firme y la causa en estado de resolver. Y CONSIDERANDO: LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES HECTOR HUGO LIENDO Y JOSE MANUEL DIAZ REYNA, DIJERON: 1. Se agravan los amparistas del rechazo liminar de su petición con fundamento en que no se configura en la especie la causal del art. 2 inc. a, ley 4915. Expresan los recurrentes agravan en relación a la vía procedimental administrativa considerado por el a quo para el análisis del juicio de admisibilidad determinando el rechazo liminar a de la acción -art. 3, Ley 4915- con base, pura y exclusiva en los supuestos previstos en el art. 2, Ley 4915. Los recurrentes expresan que el a quo transcribe citas de fallos que fundarían su decisión de rechazar esta acción en virtud de no haberse agotado la vía administrativa previa a la presentación de este amparo. Manifiestan que el juez en definitiva, acata lo dispuesto por el art. 2 inc. a, Ley n° 4915 de amparo a rajatabla, sobre todo cuando expresa que el amparo no será admitido cuando: "a) existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trata; ..." ; soslayando que este precepto ha sido en la práctica derogado por el constituyente al redactar el nuevo art. 43, CN que en la parte pertinente expresa: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Citan en abono de su posición a Silvia Díaz: "Como la norma constitucional no menciona en forma expresa la vía administrativa -tal como se ha señalado- aparecería hoy derogada la obligación de agotarla en materia de amparo, de modo tal que si el tribunal ordenara acudir a esa vía o rechazara el amparo por esa circunstancia, aparecería prima facie vulnerado el art. 43, CN. (...) Por todas estas consideraciones y por así soslayarlo la cláusula constitucional queda totalmente desterrada la posibilidad de argumentar la necesidad del reclamo administrativo previo de darse los presupuestos de admisibilidad para la acción de amparo." Abonan los recurrentes su posición con cita del Dr. Calógero Pizzolo "Con fundamento en esta redacción (se refiere a la cláusula constitucional) debe excluirse ahora la necesidad de agotar las instancias o recursos administrativos pendientes y, sobre todo desechar la vía judicial ordinaria cuando se ha transformado en una vía carente de idoneidad". En tanto que Rivas expresa que el art. 43, CN produce un "Vuelco drástico y trascendente" en el tema o exigencia de la vía procedimental previa a la acción de amparo, como requiere todavía el texto desactualizado de la ley de amparo. En definitiva manifiestan que el constituyente ha pretendido dar un giro copernicano en este tema para lograr que a través de la

acción de amparo el justiciable pase a tener una herramienta eficaz para hacer cumplir la constitución cuando se vulneran sus derechos. De este modo, sólo ha quedado como obstáculo a salvar la existencia de una acción judicial más idónea. Señalan que no puede olvidarse que se trata ahora el amparo constitucional de una "acción rápida y expedita". Agrega que existen dos "acciones" que colisionan: el amparo "legal" (defendido por el juez a quo y hoy "derogado") y el amparo "constitucional" (planificado por el constituyente y vigente plenamente a partir de 1994). No quedan dudas que ante el choque de un modelo plasmado por la ley antigua y el que diseña la Constitución, el magistrado -cuya principal misión es aplicar la ley e interpretar la Carta Magna- debe optar por esta última. Sólo procede que analice entre dos o más acciones judiciales posibles, si otra es más idónea que el amparo para hacer cesar la violación constitucional denunciada.- Abonan su posición con citas jurisprudenciales de la Corte Suprema. Agregan que Ekmekdjian sostuvo, la existencia de "vías paralelas" no puede ser obstáculo a la procedencia del amparo si la utilización de ellas trajera aparejada una frustración a los derechos presuntamente lesionados o bien un daño grave o irreparable; más aún si como sucede con el tema en cuestión, el amparo resulta imprescindible porque se requiere del accionar judicial de manera "rápida y expedita.". En definitiva, el Juez a quo sólo podría haber "inadmitido" esta acción si existiera otra acción judicial "más idónea" que el amparo para hacer cesar esta violación a los derechos constitucionales de los actores, pero nunca esgrimir el argumento ya superado por la doctrina y jurisprudencia de la vía administrativa previa. Concluyen respecto de este agravio que el rechazo por esta causal resulta manifiestamente improcedente, se basa en una apreciación meramente ritual y por lo tanto, debe acoger esta acción, siguiendo esta reciente jurisprudencia de la Corte. Como complemento de este agravio y referido a las aclaraciones y consultas del pliego y los exiguos plazos que no permiten hacer uso de ese derecho y que en consideración del a quo los amparistas se equivocan por confundir el plazo de publicación que pone en conocimiento el llamado a licitación pública con el plazo para efectuar las consultas y/o aclaraciones referidas a los pliegos. Se agravan los recurrentes por considerar las afirmaciones del A quo como lo que parece responsabilizar a los accionantes de algún grado de desidia acerca de su accionar. Se agravan en primer lugar, porque expresan que adquirieron el pliego de acuerdo a lo normado, tan sólo pocos días a partir de que se publicara el extracto del llamado a licitación en el BOP. Que como expresan en la demanda esta importante licitación sólo se ha publicado en el BOP y por cinco días (ver ejemplar de BOP del 27/4/07 ofrecido como prueba documental). Esto implica que comenzó a publicarse el lunes 23/4/07 -tan sólo seis días antes que el actor Jarast adquiriera el pliego y ocho antes que el resto). De cualquier manera sólo podrían haber efectuado "observaciones o consultas" a partir de que leyera el pliego (lo que sucedió en la fecha prevista) pues no puede cuestionarse lo que no se conoce. Y no puede atribuírseles "equivoco" alguno porque la noticia de esta licitación parece haberse guardado bajo siete llaves; sólo así se explica que no se hubiera extendido el plazo de licitación en el BOP durante un tiempo mayor o que se hubiera

difundido de otro modo (por medios radiales, gráficos o televisivos de mayor alcance o aunque más no sea a través de circulares o notas dirigidas por la autoridad convocante a quienes prestan habitualmente el servicio); o también lo exiguo de los plazos entre la publicación, venta de los pliegos y presentación de ofertas. Señalan que en definitiva, se enteraron del contenido del pliego a partir de que lo leyeron y analizaran con detenimiento, lo que sucedió a partir de la adquisición y no desde que comenzó a publicarse el llamado en el boletín oficial. Por ello, este argumento del a quo resulta inconsistente y no basta para desacreditar sus dichos en la demanda (específicamente el apartado IV.4). Señalan que, no han cuestionado el proceso licitatorio sólo por lo exiguo de los plazos para presentar consultas y/o aclaraciones (Ap. IV.4) sino por ser inconstitucional y conculcatorio de sus derechos constitucionales en gran parte, explicitados en todo el apartado IV de la demanda y parece haberse soslayado por el a quo. Que en el Apartado V.1 manifiestan que se han referido in extenso sobre el requisito de la "vía judicial más idónea", lo que parece no haber sido leído por el tribunal de primera instancia. Por estos motivos, debe también acoger este recurso y admitir la acción intentada. También se agravan los recurrentes sobre lo expresado en relación a la suspensión del acto en la Ley de Procedimientos Administrativos y que el a quo considera que los demandantes nada manifiestan respecto de cual ha sido "el impedimento que tuvieron para interponer el mismo día cuatro de mayo del cte. año los recursos contemplados en la ley 6658 -procedimiento administrativo provincial, arts. 80 y 83 -reconsideración y jerárquico-con el consecuente pedido de suspensión de los efectos del acto administrativo consistente en el llamado a licitación y en las cláusulas del pliego que estos advierten o tachan de oscuras y susceptibles de aclaración -art. 91, ley 6658". Se agravan en consideración a los actos recurribles en sede administrativa, señalando que la Ley 6658 de procedimiento administrativo en sus arts. 80 expresa: "El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito y fundadamente dentro del plazo de cinco (5) días siguientes al de la notificación, por ante la autoridad administrativa de la que emanó el acto."; pero antes de ello el art. 77 expresa: "Son impugnables mediante los recursos previstos en este capítulo los actos administrativos definitivos que lesionen derechos subjetivos o que afecten intereses legítimos, y que considerasen los impugnantes que han sido dictado con vicios que los invalidan. La interposición de estos recursos cuando fueren procedentes conforme a esta ley, será siempre necesaria a los fines de agotar la vía administrativa." Y completando el plexo normativo el art. 78 de esa misma ley 6658: "No son recurribles en sede administrativa los actos preparatorios de las decisiones, los informes, dictámenes y vistas aunque sean obligatorios y vinculantes.". Los recurrentes en consideración a dicha normativa califican al pliego de una licitación no es un acto administrativo definitivo en los términos del art. 77 señalado, sino que se trata de un acto preparatorio (aunque obligatorio y vinculante) y por lo tanto irrecurrible en los términos del art. 78. "La enumeración de la norma engloba a los actos del procedimiento que va preparando el acto definitivo, aportando elementos o realizando los pasos procedimentales necesarios para habilitar su dictado. Si bien

pueden producir efectos jurídicos, éstos resultan mediatos en relación a los particulares, por lo que no puede darse de manera directa el requisito del perjuicio a un derecho o interés legítimo, haciéndose inviable de esta forma la impugnación recursiva respecto de tales actos." (Carranza Torres, Luis. "Procedimiento y proceso administrativo en Córdoba", Vol I; al comentar el mencionado art. 77). Agregan que es conocido que un proceso de Licitación Pública tiene tres etapas: La "Preparatoria", la de recepción de las ofertas; la evaluación de las ofertas y la adjudicación. A no dudarlo, en este proceso nos encontramos dentro de la Etapa Preparatoria. "Se trata de una actividad puramente interna de la Administración, sin intervención de los administrados u oferentes." (Vélez Funes y otros. "Derecho Procesal Administrativo. T. I, p. 38). De este modo, al tratarse de actos preparatorios, los pliegos no son recurribles. Sólo podrían cuestionarse o "impugnarse" eventualmente y contar con un rechazo por inadmisibilidad formal de la administración precisamente por no ser actos administrativos firmes. Concretan agravios relacionados a la consideración del agotamiento de la vía administrativa, expresando que si se situaran en el supuesto que hubieran cuestionado o impugnado el pliego en sede administrativa, deberían haber esperado que la administración se expida acerca de dicha impugnación y recién contra ese acto administrativo intentar el Recurso de Reconsideración que plantea el a quo. Remarcan que expedirse, la Administración hubiera contado con un plazo de cinco (5) días - tenemos en cuenta lo prescripto por el inciso f del art. 67 o diez (10) si tenemos en cuenta el inc. e, cuando no los ciento veinte (120) días del inciso g que habla de las decisiones definitivas. Señalan que, recién contra actos definitivos procede la interposición del recurso de reconsideración, y entonces la espera es de cinco (5) días como mínimo para que se expida la administración (seguramente por la negativa, porque nunca se revierte una decisión en sede administrativa). Entonces, señalan los recurrentes que adquirieron los pliegos el 2 y 4 de mayo; el a quo dice que ese día deberían haber interpuesto recurso de reconsideración (en realidad debe haber querido decir "impugnar" la redacción del pliego porque nadie "reconsidera" lo que previamente no ha "considerado") y de allí contar al menos cinco (5) días (cuando no diez (10) o ciento veinte (120) días) y la apertura de sobres y propuestas era al día hábil siguiente, el día 7/5/02. Expresan que se ve claramente, no hay posibilidad para lo que "recomienda" el inferior. Señalan que el otro camino hubiera sido presentar (si el plazo lo permitiera, pero ya habían vencido los siete días que prevé el propio pliego) una "aclaratoria" para los puntos "oscuros"; recién contra esa opinión interponer una queja o impugnación y recién emprender el camino señalado en el párrafo anterior: llegaríamos mucho más tarde aún. Agregan que por último, nadie puede afirmar seriamente que la administración va a retrotraerse en una decisión administrativa ante una "consulta" o aclaratoria de un tercero. Si existiera una estadística, estos casos no deberían registrarse ni en un uno por ciento (1 %). Por ello, todo este desgaste además de extemporáneo en su respuesta, tendría además, un resultado conocido: la negativa de la administración y recién allí iniciar la vía judicial. Agregan además que para iniciar la vía contenciosa, debe previamente agotarse la

vía administrativa iniciada y esto –señalan- les habría llevado a interponer un recurso jerárquico (art. 83 de esa ley) como nos indica la resolución que impugnan, lo que hubiera dilatado aún más los plazos. Con dichas argumentaciones entienden los recurrentes que han demostrado que la solución o propuesta que brinda el a quo es impracticable, nunca hubieran de esa manera hacer cesar los efectos del acto lesivo realizado por la autoridad estatal. Concluyendo que no les quedaba otra solución que la vía aquí intentada. Expresan los recurrentes también que existe otra impresión en el planteo de primera instancia. Dado que el art. 91, Ley 6658 expresa: "La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado. La administración podrá disponerla cuando, siendo ésta susceptible de causar un grave daño al administrado, estimare que de la suspensión no se derivará una lesión al interés público." Como se ve, la regla legal es que la interposición del recurso no suspende el acto impugnado. "El artículo sienta el principio general de la no suspensión de la ejecución o del acto por la interposición del recurso. Ello encuentra su fundamento en la presunción de legitimidad y en la normativa de ejecución de los actos administrativos." (Carranza Torres, Luis. "Procedimiento y proceso administrativo en Córdoba", Vol I, p. 177; al comentar el mencionado art. 91). Agregan que toda la doctrina administrativista dice que el acto administrativo goza de los siguientes caracteres: presunción de legitimidad, ejecutoriedad, ejecutividad, impugnabilidad y estabilidad. Este aspecto tiene que ver con tres de estos cinco caracteres: la presunción de legitimidad, ejecutoriedad y estabilidad. "Se presume -iuris tantum- que el acto administrativo ha sido dictado de conformidad al ordenamiento jurídico, respetando el bloque de juricidad. Como consecuencia de ello, la Administración cuenta con atribuciones para disponer el cumplimiento del acto administrativo en su sede (ejecutoriedad propia) o bien requerir la intervención del Poder Judicial (ejecutoriedad impropia). (...) La interposición de los recursos administrativos por parte legitimada (impugnabilidad del acto) no provoca la suspensión de los efectos del acto administrativo cuestionado, salvo que una norma expresamente dispusiera lo contrario, otorgando a los recursos efectos suspensivos, o que el acto no tuviera presunción de legitimidad por adolecer de nulidad manifiesta" (CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo, t. II, p. 223). Concluyen los recurrentes que si luego de sortear todos los obstáculos que planteados señalados, hubieran llegado a la interposición del "recomendado" recurso de reposición, hubieran dado que el efecto del mismo no suspende el acto impugnado entonces bien vale la pena preguntarse ¿cuál hubiera sido el resultado de dicha interposición?. Es cierto que existe una excepción a este principio: que se demuestre un "grave daño al administrado". Este requisito obviamente está acreditado en autos, pero ... ¿de quien depende la consideración de esta exigencia?: Se responde los recurrentes de la misma administración y como es obvio, nunca se iba a considerar por parte de la demandada que este grave daño estaba configurada. En definitiva y conforme han sido desagregado uno a uno los párrafos del decisorio que "inadmitiera" la acción de amparo incoada -entienden los recurrentes- que los han rebatido demostrando que no cabe otra "acción judicial más idónea" que el amparo



interpuesto correspondiendo que se haga lugar a este recurso y admita la acción intentada, lo que así solicitan. 2. Entrando al análisis de la cuestión si bien se admite como cierto que el Art. 3 de la ley de amparo autoriza al juez al rechazo liminar de la pretensión, ello debe ser ponderado en función de que dicha facultad corresponde ser ejercitada con cautela y prudencia, decidiéndose en su ejercicio por el rechazo en la instancia de admisibilidad solo en casos en que no se susciten dudas razonables. En ese sentido se ha sostenido que “Si por el contrario, tal admisibilidad es dudosa, el juez deberá acoger la pretensión y darle trámite. En otras palabras, la facultad de rechazar in limine la acción opera con criterio estricto, y por ello el tribunal deber obrar con cautela y prudencia, estando por la admisibilidad del amparo en caso de duda. Tal limitación en la aplicación de la norma bajo análisis se justifica esencialmente por tres razones: a) Garantizar lo máximo posible la tutela de los derechos constitucionales; b) Preservar el derecho de acceso a la jurisdicción, y c) Evitar adelantar o anticipar el juzgamiento del fondo del asunto. Esta ha sido la doctrina sustentada por el TSJ, a través de su Sala CA (in re Garelli, Gabriela. 28.10.98), y así también lo ha resuelto la C5a CC Cba., que ha sostenido “El rechazo de la acción de amparo es de carácter excepcional en tanto el análisis inicial de su inadmisibilidad debe realizarse en forma cautelosa y prudente decidiéndose el rechazo solo en los supuestos indiscutibles es decir que no susciten ninguna duda” (AI 460 del 2/10/01)”, conforme María del Pilar Hiruela de Fernández en “El amparo en la Provincia de Córdoba”. P. 168 Ed. Alveroni. Por lo que con la prudencia señalada corresponde determinar si el invocado art. 2 inc. a, ley 4915 resulta suficiente para la improcedencia limitar de la acción deducida, en orden a ello y aún antes de la reforma constitucional (art. 43, CN) era pacífica la doctrina y jurisprudencia en el sentido restrictivo con que correspondía ejercer esta facultad, estableciéndose que en esta etapa “...debe cumplirse con mucha cautela y prudencia ya que el archivo de las actuaciones puede originar serios perjuicios al demandante, perjuicio no subsanable no obstante el carácter apelable que reviste la providencia que rechaza in limine la acción” (Morello Vallefin en “El amparo. Régimen procesal Tercera Edición Librería Editorial Platense SRL P. 76). El razonamiento restringido halla cimiento en que la diversidad de las causales de no admisibilidad de la acción que establecen los incisos del art. 2, ley 4.915, a los que no puede dejar de considerarse la crítica que brindan en el estado actual de la evolución doctrinaria con base constitucional, y que debe ser resuelto luego del constreñido cartabón probatorio, en la sentencia de mérito y no sin contradicción y en un marco mucho más estrecho como es al iniciarse la acción. Es así que luego de la reforma constitucional se ha considerado que el juez ya no puede rechazar ab initio la acción invocando los incisos del art. 2 -que en su mayoría están derogados por la norma constitucional- de modo que la facultad está reservada a los casos en que no existan sus presupuestos esenciales, es decir que la infundabilidad de la demanda aparezca evidente de sus propios términos. En tal sentido lo tiene sostiene numerosa doctrina que ha afirmando “Al efecto de la admisibilidad de una acción de amparo, no cabe emitir opinión sobre la fundabilidad sustancial, ni siquiera sobre la verosimilitud de la reclamación, a

la cual debe imprimirse sustanciación si no concurren, ni siquiera prima facie, falencias que pudieran autorizar una desestimación “in limine” de la demanda en las condiciones previstas en el art. 176, CPC y cuando además, el relato fáctico y jurídico contenido en aquella esgrime lesión a derechos constitucionales, cuyo esclarecimiento presupone conferir el debido acceso a la jurisdicción” (Zavala de Gonzalez, Matilde Doctrina Judicial T. 4 p. 21). En el caso concreto el magistrado fundó la repulsa principalmente por configurarse en su apreciación la causal del art. 2 inc. a, ley 4915 por no haber agotado la vía administrativa previa. Que la causal invocada por el “a quo” fundada en el inciso señalado es la que con mayor nitidez ha morigerado tal restricción formal el art. 43, CN. Este Tribunal con otra integración, en la causa "ARGAÑARAZ M. FRANCISCO GODOY JUAN CARLOS Y OTROS C/AGUAS CORDOBESAS SA -AMPARO -CUERPO DE COPIAS-", sostuvo que dicha norma ha derogado tácitamente los recaudos de admisibilidad establecidos en legislaciones de jerarquía inferior (como nuestra ley provincial 4915), que consagraban la subsidiariedad del amparo, ante la existencia de otros remedios protectores (como las vías administrativas previas o los procesos ordinarios). En tanto que el art. 43 de la Constitución establece como recaudo para la admisibilidad de esta acción "...que no exista otro medio judicial más idóneo...", tornando así inconstitucional la exigencia de transitar previamente las vías administrativas... conforme a Morello-Vallefin, en El Amparo-Régimen Procesal, p. 33, Segunda Edición. En consecuencia conforme a tal doctrina y del texto constitucional citado el amparo solo se vería desplazado ante la existencia de una vía judicial más idónea, por lo que queda marginada la comparación entre el amparo con alguna vía administrativa. En consecuencia solo ante la igualdad de medios judiciales podrán desplazarlo al amparo si resultan de mayor utilidad para el particular damnificado, pero nunca si tienen una igual o menor (véase, Rivas, "El amparo y la nueva Constitución de la República Argentina", LL 1994-E, p. 1330). En tanto que para Morello el amparo es ahora alternativa directa y principal (no subsidiaria) y para la tutela de los derechos constitucionales fundamentales no hay nada más idóneo, en principio, que el amparo" ("El amparo después de la reforma constitucional", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 1994, N° 7, p. 226 y 231). En igual sentido Adolfo A. Rivas, entiende: "Creo que no puede haber discusión acerca de la operatividad del art. 43, CN; con ello, del efecto derogatorio implícito de toda norma que se oponga o desvirtúe a dicho dispositivo y su finalidad protectora; ... El art. 43 habilita al amparo como expeditivo y rápido; el ordinario no lo es y por tanto no puede servir como medio más idóneo; ni tiene la finalidad del amparo ni opera en las situaciones en las que se da, pues aquél apunta a dar certidumbre al derecho y este sirve teniendo como presupuesto un derecho cierto..."(Rev. JA N° 6001, p. 26). Cotejando la norma constitucional con el régimen legal preexistente se advierte, que la reforma de 1994 eliminó el obstáculo impuesto por el art. 2, inc. a, Ley de Amparo, que subordinaba la admisibilidad de la pretensión del amparista a que no existieran recursos o remedios administrativos que permitan obtener la protección del derecho de que se trata. La reforma constitucional de 1994 implicó la derogación orgánica del

requisito vinculado con la existencia de otras vías administrativas "por resultar incompatibles con sus disposiciones" (Cftar.: Rev. JA N° 6010 "El Amparo Constitucional y sus relaciones con los demás cauces formales de tutela...", p. 68/69). A lo que agregamos que tratándose de problemas vinculados a la violación de garantías constitucionales invocadas, en el caso violación a los derechos de igualdad y propiedad, la demora que esos otros trámites, como el administrativo, suponen no se compadece con la urgencia en la solución de dichos conflictos, y con mayor razón frente a la variedad de hechos invocados en demanda como productores de tal lesión. Pero, aun admitiendo que la doctrina restrictiva en relación a la norma constitucional se encuentra morigerada para casos excepcionales, en que es de aplicación la doctrina del TSJ citada por el juez "a quo", en cuanto a que la tácita derogación de las normativas legales provinciales, como el inc. a art. 2, ley 4915, no repugnara a la constitución y que se adecua a la jerarquía normativa del art. 31, CN, y que excepcionalmente se considerase que el procedimiento administrativo resulta un medio más idóneo que el amparo para obtener una protección de los derechos en forma expedita y rápida. Es decir dentro de la corriente doctrinaria y jurisprudencial que considera que el art. 43, CN en tanto prevé como condicionamiento del amparo la inexistencia de "otro medio judicial mas idóneo" no deroga el art. 2 inc. a, ley 4915, ni hace que la acción de amparo deje de ser subsidiaria, viable sólo ante la inexistencia de otra vía que posibilite el adecuado resguardo del derecho invocado, como la vía administrativa que en consideración del iudicante resulta más idónea. Tal excepcionalidad en el caso en estudio ha sido suficientemente demostrado, con las argumentaciones expuestas por los recurrentes -las que se comparten- en orden a que aquella no constituye un "medio más idóneo" susceptible de desplazar al amparo, ya que como claramente lo exponen los recurrentes de la integra consideración del sistema recursivo del la Ley de Procedimientos Administrativos demuestran que en el caso, no es ella el medio más idóneo a los fines de la protección de las garantías constitucionales que se dicen lesionadas. Así, si por imperio constitucional se considera al medio más idóneo, que es todo aquél que asegura al amparista una más pronta solución del litigio, es obvio que la pretensión deducida, solo se vería asegurada por una vía rápida y expeditiva que no se satisface con la consecuente tramitación de la vía recursiva administrativa considerada en la resolución en crisis. Así se estima que la naturaleza del acto impugnado obsta a su recurribilidad por imperio del art. 78, ley 6658, o por lo menos quedará a discrecionalidad de la misma autoridad administrativa que dicto el acto impugnado la calificación de recurribilidad. Y que en el mejor de los casos si esta autoridad lo considerase recurrible - previamente deberían impugnarse la condiciones del pliego para luego de que se expida la administración, iniciar el tránsito de la vía recursiva por reconsideración pudiendo insumir hasta el recurso jerárquico, asistiendo así razón a los recurrentes que los plazos administrativos conforme a la ley respectiva, que requieren de la sustanciación del agotamiento de la vía administrativa previa, insumirían mayor tiempo que la vía de amparo. En función de lo precedentemente dicho resalta la in idoneidad de la vía propuesta en el decreto recurrido. Por otro

parte no se advierte en el caso que exista causal alguna para la declaración de inadmisibilidad in limini de la acción de deducida. En cuanto a la medida precautoria solicitada y a los fines de garantizar la doble instancias la misma deberá ser proveída por el juez a quo. Por todo ello propicio acoger la apelación y en consecuencia revocar el rechazo liminar de la acción de amparo y en su lugar ordenar se imprima trámite a la petición, sin costas atento la naturaleza del pronunciamiento (art. 130 in fine, CPC). LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO DIJO: I- Comparto la solución arribada por mis distinguidos colegas preopinantes, Dres. Héctor Hugo Liendo y José Manuel Díaz Reyna, respecto a la improcedencia del rechazo liminar de esta acción de amparo, dispuesta por el Magistrado de la causa. Acuerdo especialmente, con lo afirmado acerca de la idoneidad de la vía del amparo, por ser la acción más expedita y rápida de que dispone el accionante para la defensa de sus intereses jurídicos, teniendo en cuenta el relato circunstanciado efectuado en la demanda y la documentación adjunta a dicha presentación inicial. Pues, más allá de las posturas doctrinarias articuladas en torno al inc. a) del art. de la ley de amparo provincial 4915, similar en su texto a la ley de amparo nacional 16.986, cuyas conclusiones han sido citadas en el voto que me precede, las que no comparto plenamente, en el caso traído a decisión la acción de amparo se presenta como la vía judicial más adecuada a tenor de la naturaleza de la pretensión demandada. Me permito agregar aquí, algunas consideraciones que ya sostuve en oportunidades anteriores, por citar algunas de ellas, véase el caso "DOMINGUEZ ROSA ARACELI C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA – AMPARO - RECURSO DE APELACION Expte. Nro. 706551/36", marzo de 2005, entre otros pronunciamientos similares dictados como integrante de la Cámara Sexta en lo Civil y Comercial. Las conclusiones a las que arribé en el citado resolutorio, acuerdan con mi postura doctrinaria expuesta en "EL RECHAZO "IN LIMINE" DE LA ACCIÓN DE AMPARO - ¿Una figura destinada a subsistir en la nueva ley reglamentaria?" (LL, 1997-B, 419). He manifestado, que las condiciones de admisibilidad y procedencia de la acción de amparo, se encuentran supeditadas a la existencia de lesión o daño que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con ilegalidad manifiesta las libertades, derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la Nación y de la Provincia. El sentenciante en su carácter de órgano jurisdiccional encargado de decidir la suerte de la acción, debe realizar al tiempo de presentarse la demanda un juicio de admisibilidad a la luz de las directrices que surgen del art. 1 y 2, ley 4915 y art. 43, CN. En esa inteligencia, halla su base el criterio de subsidiariedad del amparo, respecto de otras acciones. Esa interpretación se asienta en la correlación de las disposiciones de los arts. 43, CN, con el art. 2, ley 4915 en vigencia y con su análogo el art. 2, ley 16.986. En efecto, luego de la reforma introducida en el año 1994 señala el art. 43 de la Ley Fundamental, que "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace,

con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derecho y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley...". La frase "siempre que no exista otro medio judicial más idóneo", permite inferir que en la economía de la Ley Fundamental, la acción de amparo funciona como un remedio excepcional, como una alternativa o como un medio procesal subsidiario de otras acciones o vías judiciales, para conculcar las lesiones o perjuicios producidos a un titular de derechos amparados por cláusulas constitucionales o legales. Esta interpretación que asigna a la acción de amparo una posición subsidiaria ha sido acordada al dispositivo del art. 43 por la generalidad de la doctrina especializada que se ha ocupado del nuevo texto constitucional. Reconociéndose que por ese carácter subsidiario, el amparo no constituye una acción supletoria de otras vías judiciales que sean eficaces. Apreciado así el remedio del amparo como una vía subsidiaria de otras más expeditas, bien se ha puntualizando que la existencia de otras vías judiciales no obsta al uso del amparo si ellas, son menos aptas para la tutela inmediata que se debe deparar (ver Bidart Campos, Germán "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Ed. Ediar, Bs. As., 1995, VI, p. 311/312). En las recientes publicaciones de los tratadistas referidas al papel del nuevo art. 43 en el concierto de las acciones procesales existentes, se ha considerado con profundidad y extensión el tema de la subsidiariedad del amparo. Se alude a la voluntad del constituyente en la redacción de la cláusula constitucional y, reseñándose las diversas posiciones que se adoptaron en la Convención Constituyente, Sagües estima hubo dos tesis y triunfó una: La concepción del amparo como remedio residual o supletorio, en cuanto a otros procedimientos judiciales o administrativos siempre que fueren útiles, por supuesto para encarar el acto lesivo (El autor había antes considerado la subsidiariedad de la acción en "Amparo, hábeas data y hábeas corpus en la reforma constitucional", LL 7/10/94). Lino E. Palacio aborda también este tema y luego de reseñar las posturas existentes en el ámbito de la doctrina, se refiere por un lado, a los discernimientos restrictivos que sostienen Sagües y Barra que consideran limitada la posibilidad de recurrir al amparo, y por el otro, a las líneas más amplias sostenidas en forma separada por Morello y Rivas ("El amparo y la nueva Constitución de la República Argentina", LL 1994-E, 1330), que no encuentran obstáculos o vallas procesales para el ejercicio del remedio excepcional. Como conclusión Palacio señala, que el amparo "comporta una alternativa principal, sólo susceptible de desplazamiento por otras vías más expeditas y rápidas". Y agrega, que en la legislación procesal Argentina no se hallan regulados procedimientos judiciales que ostenten esas condiciones, "es decir que exhiban, a causa de su simplicidad y correlativa celeridad, mayor idoneidad que el proceso de amparo...". Gozaíni, al encarar la cuestión de la subsidiariedad de la acción, expresa que se ha mantenido la posición que respalda el art. 2, ley 16.986 al considerar como medio procesal justo y adecuado contra un proceder arbitrario. Y, resume el pensamiento con una cita apropiada de la Corte Suprema que señala "la acción de amparo constituye un remedio de excepciones, cuya utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas pueda afectar derechos constitucionales, máxime

cuando su apertura requiere circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y la demostración, por añadidura, de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del citado proceso constitucional" (CSJN, 4/10/94 "Ballesteros, José s/ acción de amparo" Fallos: 317:1128). Criterio que la Corte Suprema actual sigue manteniendo. En esa línea, la idoneidad de la acción de amparo, está dada entre otros aspectos, por las características de la pretensión y el estado probatorio que requiera, ya que si el actor necesita de "abundante prueba o debate" para acreditar la razón de su derecho, no se logra concretar en el "comprimido trámite del amparo". De allí, que la vía ágil, eficaz y sencilla del amparo, se halla estrechamente relacionada con la plataforma fáctica de la pretensión intentada y la naturaleza del derecho que la sustenta. El criterio citado que estrecha las facultades de los magistrados de desestimar in limine la acción de amparo, encuentra su respaldo en el texto del art. 43, CN, posterior al indicado art. 3, ley 4915 y su similar de la ley 16.986, pues la reforma constitucional de 1994 introdujo en el marco magno, nuevas perspectivas dirigidas a reafirmar el derecho a la prestación de la jurisdicción para los justiciables. Este derecho inalienable a la prestación de la jurisdicción a través de un procedimiento que asegure el derecho a ser oído y el derecho de defensa de todas las partes implicadas en un proceso, se deriva además de los convenios internacionales que la Nación Argentina ha suscripto y que gozan de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN). La reforma constitucional operada no ha hecho más que renovar dichas garantías, las que se han visto ampliadas con la incorporación al texto constitucional de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) cuyo art. 8, titulado "Garantías Constitucionales", establece en su art. 1: "Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". En lo atinente al amparo, el art. 25 de la aludida Convención, estatuye: "Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuanto tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los estados partes se comprometen : a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso". De igual modo, otros pactos internacionales prevén a través de diversas disposiciones la necesidad de que los regímenes jurídicos de las naciones contratantes, contemplen recursos sencillos y breves que sean idóneos para

amparar los derechos y garantías de los individuos. Así lo hacen también, el art. 8, Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 2, Pacto Internacional de Derechos Culturales, Civiles y Políticos. Y, dentro de ese contexto, pueden mencionarse también los recaudos emergentes de la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", la "Convención Americana de los Derechos Humanos". Que el principio de derecho de prestación de la jurisdicción con independencia del derecho del pretensor, está ahora incorporado al ámbito normativo por el citado art. 25, ap. 2, punto a) del Pacto de San José de Costa Rica, con las implicancias legales que se derivan. La garantía impuesta a los países contratantes, sobre la actuación del sistema judicial, que en nuestro país es el "legal del Estado", quien debe decidir sobre los derechos de toda persona que articule el recurso sencillo y práctico del amparo, se opone a la posible desestimación "liminar" de la acción. La decisión de los derechos, implica la apertura del ámbito de cognición judicial, a fin de que, -tránsito procedimental mediante-, se dicte la sentencia admisorio o negatorio de la pretensión. (confme. LL, 7/9/95, p. 2/4)". Los acuerdos supranacionales recordados, estipulan a través de cláusulas diversas, la necesidad de que los Estados - Partes aseguren una vía "sencilla", "breve", "rápida", "efectiva", como forma de garantizar o tutelar las garantías constitucionales de los ciudadanos y precaver así conductas estatales o particulares, inconstitucionales o antijurídicas. De modo tal, que sólo cuando la vía del amparo no sea la acción idónea para perseguir el reconocimiento de los derechos demandados por requerir la pretensión de una mayor amplitud de la etapa probatoria, se admitiría el rechazo liminar. Pero esto no ocurre en la especie dado que en el reclamo de la parte actora, Residuos Patógenos, en contra de la Licitación Pública 16/06, son cuestiones de neto corte jurídico o de puro derecho susceptibles de ser tramitadas, ventiladas y resueltas por la vía sumaria del amparo. Que en definitiva corresponde hacer lugar al recurso intentado y en consecuencia, revocar el proveído recurrido ordenando al Tribunal imprimir a la demanda de amparo el trámite de ley. Por lo expuesto, normas legales citadas, SE RESUELVE: 1) Acoger el recurso de apelación deducido por los amparistas y en consecuencia revocar el rechazo liminar de la acción y en su lugar ordenar al juez a quo imprima trámite a la petición, como asimismo proveer a la medida precautoria solicitada. 2) Sin costas atento a la naturaleza del pronunciamiento (Art 130 CPC). 3) Protocolícese, hágase saber y bajen.

Héctor Hugo Liendo, José Manuel Díaz Reyna y Silvia B. Palacio de Caeiro